

1502698-87.2021.8.26.0544

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MAURICIO GARIBE

Comarca: Jundiaí / SP

Foro: Foro de Jundiaí

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/05/2022

... autos.

Saliento, por fim, que o delito de tráfico de drogas é um crime de ação múltipla ou conteúdo variado. Com efeito, o tipo penal é composto por diversos verbos e, tratando-se de tipo penal misto alternativo, praticando, o agente, qualquer um dos verbos núcleo do tipo incidirá no delito de tráfico de drogas, sendo prescindível a efetiva mercancia ilegal.

A conduta de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jundiaí / SP

1ª Vara Criminal

Largo São Bento, s/nº, Centro - CEP 13201-035, Jundiaí-SP

Fone: (11) 4586-8111 - E-mail: jundiai1cr@tjsp.jus.br

Horário de atendimento ao público: 13h00min às 17h00min

1502698-87.2021.8.26.0544 - lauda

CONCLUSÃO

Aos 24 de maio de 2022, faço estes autos conclusos ao Meritíssimo Juiz de Direito titular da 1ª Vara Criminal da Comarca de Jundiaí, Estado de São Paulo, Doutor Maurício Garibe. Eu, Nara Visousan Santos do Nascimento, Assistente Judiciário.

SENTENÇA

Processo nº:

1502698-87.2021.8.26.0544 - 2021/001941

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Réu:

MATEUS BRAGA DOS SANTOS e TIAGO RUSSO GOMES

Juiz de Direito: Dr. MAURICIO GARIBE

Vistos.

MATEUS BRAGA DOS SANTOS e TIAGO RUSSO GOMES, qualificados nos autos, estão sendo processados por infração ao disposto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, c.c. artigo 29, "caput", do Código Penal, porque, no dia 02 de novembro 2021, por volta das 23h00min, na Rua Nair Bartolomeu do Prado, n. 10, Novo Horizonte, nesta cidade e comarca de Jundiaí, estariam trazendo consigo, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar:

79,94g de maconha, contendo a substância tetrahidrocannabinol, divididos em 38 (trinta e oito) invólucros plásticos ;

3,62 de cocaína, na forma de crack, divididos em 38 (trinta e oito) frascos plásticos;

21,70g de cocaína em pó, divididos em 31 (trinta e um) microtubos plásticos do tipo

Eppendof;

2 comprimidos de Ecstasy, além da quantia de R\$ 148,00 (cento e quarenta e oito reais), em notas fracionadas.

Oferecida e recebida a denúncia, os réus foram pessoalmente citados e apresentaram defesa prévia, sobrevivendo audiência de instrução, debates e julgamento.

Em alegações finais, a representante do Ministério Público opinou pela integral procedência da ação penal, condenando-se os réus nos termos da denúncia. Quanto à dosimetria da pena, com relação a Tiago, requereu seja sua condenação mais antiga considerada como maus antecedentes para o fim de fixar a pena-base acima do mínimo legal; o reconhecimento da circunstância agravante da reincidência e circunstância atenuante da confissão, as quais podem ser compensadas, negando-se a aplicação do parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei de Drogas, bem como fixando-se o regime fechado para início de cumprimento de pena; com relação a Mateus, cabível a aplicação do parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei de Drogas, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, fixando-se o regime aberto. Por fim, requereu o perdimento do dinheiro apreendido em favor da União.

A Defesa, por seu turno, requereu a absolvição dos réus, com fundamento no art. 386, VII, do CPP. Subsidiariamente, com relação a Mateus, requereu a desclassificação para o delito tipificado no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006. Em caso de entendimento diverso, requereu, subsidiariamente: Na primeira fase, a fixação da pena-base no mínimo legal; com relação a Mateus, requereu o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa; com relação a Tiago, a compensação integral da majorante da reincidência com a atenuante da confissão deduzida em Juízo; na terceira fase da fixação da reprimenda, com relação a Mateus, requereu a aplicação da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, em seu patamar máximo; no que tange ao cumprimento da pena, para Mateus, requereu seja fixado regime ABERTO (com fulcro nos artigos 33 e 59, ambos do Código Penal), bem como que seja a pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos (art. 44 do CP), devendo ser considerado o tempo de prisão provisória em situação idêntica a do regime fechado, nos termos do artigo 387, §2º do CPP (acusado preso em 20 de abril de 2022). Por fim, pugnou pelo direito de o réu apelar em liberdade. Com respeito ao acusado Tiago, requereu seja fixado regime diverso do fechado, nos termos do artigo 33, §3º do Código Penal e artigo 387, §2º do CPP (réu preso preventivamente desde 2 de novembro de 2021 – fls. 68/69), bem como o direito de o acusado apelar em liberdade.

Relatados no essencial. DECIDO.

A materialidade da infração penal imputada aos réus restou comprovada por meio do auto de exibição e apreensão de fl. 38, comprovante de depósito de fl. 83, laudo pericial de fls. 240/246, laudos de exame químico toxicológico de fls. 92/94 e 111/115, que resultaram positivo para maconha, crack, cocaína e ecstasy, substâncias descritas na denúncia, consideradas entorpecentes e que possuem capacidade para causar dependência física e psíquica, bem como pelo depoimento de duas testemunhas comuns, colhidos em audiência.

No tocante à autoria, verifica-se que o acusado Mateus, em juízo, negou a prática delitativa, aduzindo, em síntese, que é usuário de drogas e foi ao local dos fatos comprar maconha, sendo que quando foi abordado pelos policiais já tinha comprado, estava com a maconha e R\$ 10,00 no bolso. Disse que comprou a maconha do corréu Tiago.

Já o acusado Tiago, em juízo, confessou a prática delitativa, aduzindo, em síntese, que de fato estava traficando na data dos fatos e que Mateus não estava traficando e, sim, foi comprar maconha consigo.

Assim, apreciadas autoria e materialidade, passo à análise dos argumentos expendidos pelas partes, em cotejo com a prova produzida sob o crivo do contraditório.

E, em tal contexto, entendo que a ação penal procede, parcialmente.

Com efeito, os réus silenciaram quando ouvidos na polícia, situação essa que demonstra terem deixado de lado a primeira oportunidade de defesa que se abria para

a sua autodefesa.

Conforme já decidido "... embora a opção pelo silêncio derive de previsão constitucional, ela não inviabiliza o convencimento judicial no sentido desfavorável ao réu, pois a reação normal de um inocente é proclamar, com insistência e ênfase, a sua inocência, não reservar-se para prestar esclarecimento apenas em Juízo."

As testemunhas de acusação Leonardo Henrique Garcia e Igor Dias Ribeiro, por sua vez, em juízo, corroborando as declarações prestadas na fase policial, confirmaram como se deu a abordagem dos réus, bem como a apreensão dos entorpecentes na posse deles.

Não há qualquer irregularidade na oitiva de policiais envolvidos em sua prisão e que, como qualquer pessoa, prestam depoimento sob compromisso.

De se ressaltar, também, que agentes da autoridade policial que são, seus depoimentos são revestidos de maior credibilidade, notadamente em hipóteses de tráfico de entorpecentes. Em tal sentido: "Vetusta e vazia, data venia, a objeção, que os causídicos, vez por outra, ainda insistem em opor perante os tribunais, argumentando por argumentar. Ora todo e qualquer testemunho, por cediço, é de valor relativo, pouco importando a profissão, sexo, credo, grau de instrução, posição social ou outro qualificativo do testificante. Em outras palavras, é de valia aferível em face do conjunto instrutório, somente podendo ser, total ou parcialmente, desqualificado, se outros elementos do acervo probatório assim o demonstrarem ou se o testemunho for prestado por inimigo capital ou parente ou amigo íntimo do acusado, ou, ainda, por qualquer pessoa particularmente interessada no resultado do julgamento, defeitos estes, porém, sujeitos a demonstração e comprovação por meio de contradita e, conquanto assim, se o testificante, à luz do conjunto de provas, da verdade real se apartar. Não se pode aceitar parti pris, preconceito vazio, repulsa genérica, apenas calcada na profissão da testemunha. É de mister, pois, demonstrar e provar motivo concreto, particular ao testemunho no caso em julgamento, para destituí-lo de valor probante." (TJSP – AP. 413.648-3/4-00, Rel. Ericson Maranhão).

Também, neste sentido o posicionamento do Supremo Tribunal Federal: "o valor de depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (STF HC 73518-5 Rel. Celso de Mello DJU 18.10.96, p. 39.846). Ademais, importante destacar a quantidade e variedade de drogas apreendida, bem como a forma de acondicionamento, assim como a apreensão de R\$ 148,00, em dinheiro, fortes indícios de que o entorpecente, de fato, se destinava ao comércio ilícito. Desta forma, a traficância foi confirmada pelos elementos de prova carreados aos autos.

Saliento, por fim, que o delito de tráfico de drogas é um crime de ação múltipla ou conteúdo variado. Com efeito, o tipo penal é composto por diversos verbos e, tratando-se de tipo penal misto alternativo, praticando, o agente, qualquer um dos verbos núcleo do tipo incidirá no delito de tráfico de drogas, sendo prescindível a efetiva mercancia ilegal.

A conduta de qualquer dos verbos contidos no artigo 33, "caput", da Lei de Drogas, implica em tráfico, sendo o dolo sempre genérico. Por isso, dispensável a prova efetiva e direta de qualquer ato de comércio clandestino de droga, sendo bastante a prova do conjunto de indícios e presunções envolvendo o acusado.

Desta forma, o conjunto probatório comprovou a prática do delito de tráfico de drogas, descrito no caput do artigo 33 da Lei de Drogas.

Assim, os elementos de convicção constantes dos autos são suficientes para a responsabilização dos acusados, que traziam consigo drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Inviável, portanto, a desclassificação da conduta imputada ao acusado Mateus para o delito previsto no artigo 28 da Lei de Drogas. Basicamente, porque, à vista da descrição da ação policial, com o encontro de entorpecentes, prontas para a venda, não há que se falar em mera posse de drogas para consumo próprio, pois, por mais que se admitisse eventual dependência química do réu, nada explica a presença de tamanha variedade de drogas em via pública.

Desse modo, a absolvição por falta de provas é meta impossível de ser alcançada, já que a dinâmica dos fatos conduz à conclusão desfavorável aos acusados.

Assim, e evidenciada a responsabilidade dos réus pelo crime de tráfico de entorpecentes que lhes é imputado, passo à dosagem das penas, atento às diretrizes do artigo 59 do Código Penal.

Na primeira fase, observo que o acusado Mateus é primário e sem antecedentes criminais. Já o corréu Tiago é reincidente específico, o que será oportunamente apreciado. Ademais, Tiago é portador de maus antecedentes, possuindo uma condenação por tráfico de drogas incapaz de gerar reincidência. Assim, atento aos demais critérios do artigo 59 do Código Penal, com relação a MATEUS, a pena base deverá ser fixada no mínimo, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, estabelecida a unidade no piso mínimo. Entretanto, fixo a pena base do acusado TIAGO acima do mínimo legal, estabelecendo-a em 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, estabelecida a unidade no piso mínimo.

Na segunda fase, com relação ao acusado MATEUS, ausentes agravantes, faz-se presente a atenuante genérica da menoridade relativa. Contudo, consoante a Súmula 231 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a incidência de atenuantes não pode conduzir à redução da pena aquém do mínimo legal, razão pela qual, nesta fase da dosimetria da pena, deve ser mantida a pena base fixada.

Ademais, considerando a incidência da causa de diminuição de pena prevista no parágrafo quarto do artigo 33 da Lei de Tóxicos, diminuo as penas aplicadas em ½ (metade), estabelecendo-as em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, mantida a unidade no mínimo, penas estas que torno definitivas ante a ausência de modificadoras a considerar.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça (julgamento da Petição nº 11.796/DF), após parecer favorável da Procuradoria Geral da República, adotou o seguinte entendimento em relação aos crimes de 'tráfico privilegiado' (aqueles cometidos por agente primário e de 'bons antecedentes', que não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa).

Assim, aplico o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, isto é, será considerado crime de natureza comum o 'tráfico privilegiado'.

Por fim, considerando que o acusado é primário, não possui antecedentes criminais, o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça e o acusado não tem vínculo com organização criminosa, entendo possível a substituição da pena privativa de liberdade aplicada por pena restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade, por igual período, nos termos em que fixada pelo Juízo das Execuções Criminais da Comarca, conforme o artigo 44 do Código Penal.

Nesse particular, consigno que, conquanto a pena privativa de liberdade cominada seja superior a 1 (um) ano, foi procedida sua substituição por uma única pena restritiva de direitos.

Ora, a substituição das penas privativas de liberdade por penas restritivas de direito é direito subjetivo do acusado, desde que se encontrem presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva estabelecidos pelo Legislador.

E, na dicção do parágrafo 2º, do artigo 44 do Código Penal, na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos; se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos.

Ou seja, não é consequência automática que a pena privativa superior a 1 (um) ano seja substituída por 2 (duas) penas restritivas, tão somente pelo montante da pena corporal.

Trata-se de faculdade atribuída ao Juiz, que poderá determinar que a substituição

seja feita por uma ou por algumas penas restritivas, quando as circunstâncias do artigo 44, inciso III, do Código Penal (isto é, a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado) indicarem que essa substituição seja suficiente.

Assim, na hipótese deste processo, vejo que a substituição da pena privativa de liberdade por uma única pena restritiva de direitos mostra-se coerente e adequada à situação do acusado e às circunstâncias do crime.

Na hipótese de descumprimento da pena restritiva de direito, Mateus iniciará o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime aberto, sendo-lhe facultado o direito de recorrer desta sentença em liberdade.

Com relação ao corréu TIAGO, na segunda fase, presente a circunstância atenuante da confissão espontânea, motivo pelo qual compenso a atenuante com a agravante da reincidência, de forma que mantenho a pena em 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, mantida a unidade do piso mínimo, a qual torno definitiva ausentes modificadoras a considerar.

Esclareço, por fim, que se mostra incabível o reconhecimento do crime em sua forma privilegiada, notadamente em razão da reincidência, o que demonstra ter o réu vínculo estreito com o crime organizado e que não era iniciante no tráfico e vinha se dedicando a esta atividade criminosa.

Também não estão preenchidos os requisitos objetivos do artigo 44 do Código Penal com relação a ele, pelo que impossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Tiago iniciará o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime fechado, sendo este o mais adequado para o cumprimento dos requisitos de prevenção e repressão ao crime cometido, sendo-lhe negado o direito de recorrer desta sentença em liberdade, uma vez que se encontram presentes os requisitos que determinaram a manutenção da custódia cautelar reforçados, ainda mais, por esta sentença.

III - Dispositivo. Ante o exposto e pelo mais dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO PENAL para CONDENAR MATEUS BRAGA DOS SANTOS, qualificado nos autos, por infração ao disposto no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/2006, c.c. artigo 29, "caput", do Código Penal a 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade aplicada por pena restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade, por igual período, nos termos em que fixada pelo Juízo das Execuções Criminais da Comarca, fixado o regime aberto em caso de descumprimento E para CONDENAR TIAGO RUSSO GOMES, qualificado nos autos, por infração ao disposto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, c.c. artigo 29, "caput", do Código Penal a 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, estabelecida a unidade no piso mínimo, pena esta a ser cumprida em regime inicial fechado, tudo conforme fundamentação acima.

Expeça-se, in continenti, alvará de soltura clausulado com relação ao acusado Mateus.

Recomende-se o corréu Tiago onde se encontrar.

Defiro a gratuidade judiciária, nos termos da Lei.

Oficie-se à autoridade policial, comunicando-se que fica autorizada a incineração da substância entorpecente apreendida.

Liberem-se os valores apreendidos (incluídos os acréscimos decorrentes de seu depósito judicial) em favor das entidades assistenciais cadastradas, a rigor do disposto na Resolução nº 154/2012 do CNJ, uma vez que não há provas de sua propriedade ou origem lícita.

Após o trânsito em julgado, lancem-se o nome dos réus no rol dos culpados, extraiam-se guias de recolhimento, procedam-se as anotações e as comunicações necessárias, inclusive ao Setor de Guarda de Objetos da Comarca, se preciso, autorizando a destruição das apreensões até então não reclamadas e, com as cautelas de praxe, archive-se.

P.I. Cumpra-se.

Jundiaí, 25 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA